

1521720-12.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MANOELA ASSEF DA SILVA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 15ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

PAULO SERGIO SANTOS DA SILVA

Juiza de Direito: Dra. MANOELA ASSEF DA SILVA

Vistos.

PAULO SÉRGIO SANTOS DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 c.c. artigo 61, inciso II, alínea "j" do Código ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

15ª Vara Criminal

Rua Dr. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

1521720-12.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1521720-12.2021.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

PAULO SERGIO SANTOS DA SILVA

Juiza de Direito: Dra. MANOELA ASSEF DA SILVA

Vistos.

PAULO SÉRGIO SANTOS DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 c.c. artigo 61, inciso II, alínea "j" do Código Penal, porque, segundo a inicial acusatória, no dia 09 de setembro de 2021, por volta de 10h15, em período de calamidade pública (Decreto Estadual 64.879, de 20/03/2020), na Rua Carlos dos Santos, nº 800, Vila Medeiros, nesta cidade e comarca da Capital/SP, guardava drogas em 02 (duas) bolsas para fins de comércio e entrega a terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal, consistentes em 09 (nove) tubos de lança-perfume, com volume de 270 ml, 53 (cinquenta e três) porções de cocaína sob a forma de crack, com peso de 19,4g, 23 (vinte e três) porções de cocaína, com peso de 12,8g, 01 (uma) porção de ecstasy, com peso de 0,4g, e 24 (vinte e quatro) porções de maconha, com peso de 53,8g, além de R\$ 50,45 (cinquenta reais e quarenta e cinco centavos) em espécie, dinheiro

produto do comércio dos entorpecentes (fls. 76/78).

A denúncia foi recebida (fls. 87/89), o réu foi citado (fl. 102) e apresentou Resposta à Acusação (fls. 106/111).

Mantido o recebimento da inicial acusatória (fls. 116/117).

Designou-se audiência de instrução, debates e julgamento, durante a qual foram ouvidas as testemunhas comuns e, ao final, o réu foi interrogado (fls. 155/158).

Encerrada a instrução criminal, o Ministério Público pugnou pela condenação do acusado, nos exatos termos da denúncia (fls. 155/157).

A Defesa, por sua vez, pleiteou a absolvição do réu por insuficiência probatória.

Subsidiariamente, requereu i) a desclassificação para a infração tipificada no artigo 28 da Lei 11.343/06, vez que o acusado é usuário de drogas; ii) a fixação da pena-base no mínimo legal; iii) o afastamento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea 'j', do Código Penal; iv) a aplicação do redutor do artigo 33, § 4º da Lei 343/06 em sua fração máxima; v) a fixação do regime aberto; vi) a substituição da pena privativa de liberdade por outras penas restritivas de direitos; e vii) a concessão do direito de apelar em liberdade (fls. 157/158).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação comporta parcial procedência.

A materialidade e a autoria delitiva foram devidamente comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante (fls. 01/02), Termos de Depoimentos (fls. 03 e 04), Boletim de Ocorrência (fls. 07/12), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 14/15), Laudo de Constatação (fls. 26/30), Depósito Judicial do Dinheiro Apreendido (fl. 67), Relatório Final (fls. 68/69) e Laudo Químico-Toxicológico Definitivo (fls. 133/136), bem como pela prova oral produzida em juízo sob o crivo do contraditório. William Gomes Ferreira, policial militar, narrou que estava, juntamente de sua colega de farda, em patrulhamento "pela região do Jardim Brasil, Parque Edu Chaves" quando visualizaram o veículo Fiat/Palio no contrafluxo da via, "não sendo possível ver o condutor"; o carro conduzido pelo réu possuía películas escuras nos vidros; decidiram pela abordagem e deram ordem de parada ao condutor, a qual fora obedecida. Indagado sobre a documentação do veículo e se havia algo de ilícito no automóvel, inicialmente, o réu asseverou "que não tinha nada"; novamente perguntado, o acusado assumiu a prática delitiva - "Ele informou: - Senhor, perdi". Continuou com a diligência a fim de vistoriar o interior do automóvel; ao abrir a porta do passageiro, "já foi possível visualizar duas bolsas, e ao abrir, uma delas com dinheiro, cinquenta reais e algumas moedas, e, na outra bolsa, entorpecentes, diversos tipos, embalados, fracionados, totalmente prontos para a venda" - "tinha ecstasy, maconha, cocaína, crack, lança-perfume". Perguntado sobre as drogas, o réu disse que estaria transportando-as para "outro local", "outra biqueira". Explicou que o local onde o réu fora abordado "já é conhecido como ponto de tráfico de drogas". O acusado foi preso em flagrante e conduzido ao distrito policial. Reconheceu o réu em juízo como sendo a pessoa que deteve no dia da ocorrência. Beatriz Batista de Faria Nogueira, policial militar, prestou depoimento harmônico e congruente, no mesmo sentido de William. Detalhou a quantidade de drogas apreendidas e reafirmou que não tiveram dúvida da atividade ilícita praticada pelo réu, porquanto o próprio disse que estaria fazendo o transporte das drogas para "outra biqueira". Reconheceu o acusado em juízo.

Na fase investigativa, PAULO SÉRGIO permaneceu em silêncio (fls. 05).

Em seu interrogatório judicial, o réu negou os fatos. Aduziu que estava na condução de seu veículo quando os policiais determinaram que parasse; obedeceu a ordem de parada. Ao ser indagado, disse aos policiais que só tinha 03 (três) porções de maconha consigo, para seu uso pessoal. Estava com a quantia de dinheiro apreendida; colocaria gasolina no carro com o valor. Os policiais pediram para que descesse do veículo e obedeceu; informou aos policiais que o veículo estava em seu nome, mas que não possuía habilitação. Foi levado até a viatura policial e foi colocado no porta-malas, enquanto os policiais realizavam a pesquisa sobre o seu nome. A policial permaneceu em guarda, na viatura, enquanto o policial foi até o veículo, a fim de vistoriá-lo. Algum tempo depois, o policial regressou com as 02 (duas) mochilas, dizendo que estavam no seu carro. Não sabe de onde surgiram as mochilas, porque não

acompanhou a vistoria no veículo. Não havia mochilas com drogas no seu carro. Elucidou que ganhou a liberdade provisória neste feito criminal; contudo, foi preso por outro processo, o qual responde, novamente, pelo crime de tráfico de drogas. Estas são as provas trazidas pelas partes e, diante delas, outra solução não há senão condenar o acusado.

Por primeiro, a versão do réu ficou isolada do conjunto probatório.

Veja-se que, aliado aos depoimentos dos policiais, a quantidade e variedade de drogas apreendidas, sua forma de acondicionamento e o contexto em que o réu fora detido já são suficientes para caracterizar o crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06, restando provada a origem espúria da quantia apreendida. A este propósito, é expressiva a jurisprudência, merecendo destaque o seguinte julgado: RECURSO ESPECIAL. PENAL. ART. 33, CAPUT, E § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. DOLO ESPECÍFICO. INEXISTÊNCIA. 1. Para a ocorrência do elemento subjetivo do tipo descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, é suficiente a existência do dolo, assim compreendido como a vontade consciente de realizar o ilícito penal, o qual apresenta 18 (dezoito) condutas que podem ser praticadas, isoladas ou conjuntamente. 2. O tipo penal descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 não faz nenhuma exigência no sentido de que, para a caracterização do crime de tráfico de drogas, seja necessária a demonstração de dolo específico, notadamente quanto ao fim de comercialização do entorpecente. 3. Recurso especial provido, para cassar o acórdão recorrido e, conseqüentemente, restabelecer a sentença condenatória. (REsp nº 1361484/MG, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, J. 10.06.2014, DJe 13.06.2014).

É de asseverar, ainda, que o simples fato de testemunhas ouvidas serem policiais nada significa para que sejam desconsiderados seus depoimentos ou que estes sejam recebidos com reservas. Saliente-se que pequenas divergências em seus relatos, normais em virtude de participarem de várias diligências semelhantes e em razão do tempo decorrido, não retiram o valor probatório dos depoimentos, porquanto seus aspectos nucleares afiguram-se congruentes e concatenados. Neste sentido: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO EM SEGUNDO GRAU. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS COLHIDOS EM JUÍZO. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS. VALIDADE. [...]. ORDEM DENEGADA. 1. Inexiste óbice no fato de estar a condenação embasada no depoimento dos policiais responsáveis pelo flagrante do corréu, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos de prova. Precedente. [...] (HC 418.529/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 17.04.2018, DJe 27.04.2018)

Por conseguinte, é idônea a prova oral produzida pela acusação.

Em outras palavras, ficou bem demonstrado pelo conjunto probatório – prova oral e depoimentos prestados em solo policial (fls. 03 e 04) – que as drogas estavam em poder de PAULO SÉRGIO e seu destino era a mercancia ilícita.

De outro lado, o pedido de desclassificação formulado pela defesa técnica não comporta acolhida.

A condição de dependente químico não tem o condão de excluir automaticamente o enquadramento típico do crime de tráfico de drogas, notadamente porque, em grande parte dos casos, os usuários de entorpecentes, infelizmente, praticam a mercancia ilícita para conseguirem sustentar o próprio vício. Nesse sentido:

“A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se mesclam no mesmo agente, preponderando a última, de maior gravidade” (RJ TJ 101/498).

É dizer, o pedido não veio amparado por qualquer documento ou testemunho contundente que fizesse possível a desclassificação pretendida, não tendo a defesa suplantado o ônus que lhe recaía (CPP, art. 156). Aliás, é pouco crível que o réu estivesse em posse de considerável quantidade e variedade de drogas para seu uso exclusivo.

Diante de todo o conjunto probatório formado nos autos, ficou exaustivamente atestado que as drogas encontradas em poder do réu realmente destinar-se-iam ao consumo de terceiros.

Portanto, caracterizada a infração penal, a condenação é medida que se impõe.

Passo à dosimetria das penas.

O réu tem 24 (vinte quatro) anos, vive com uma companheira, possui 01 (um) filho de 07 (sete) anos e 01 (um) enteado de 03 (três) anos de idade. Seus filhos "estão na escola agora". Estudou até o 1ª ano do Ensino Médio; interrompeu os estudos aos 17 (dezessete) anos, para trabalhar "em uma firma de móveis, de artesanatos". Trabalhava na Avenida do Estado como autônomo "no farol", vendendo acessórios veiculares; ganhava, por mês, aproximadamente R\$ 2.000,00 (dois mil reais). Mora em casa própria, da sua genitora. Nunca foi processado.

Inicialmente, analisando-se as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal (culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime) e no artigo 42 da Lei nº 11.343/06, tem-se que a pena-base deve ser fixada no patamar mínimo cominado à espécie, isto é, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes.

Neste ponto, nada obstante o preclaro entendimento do i. representante do Ministério Público, a agravante da calamidade pública deve ser afastada, porquanto não existem elementos suficientes que indiquem que o acusado aproveitou-se da situação da emergência sanitária da pandemia da COVID-19 para praticar o delito imputado. Nesse sentido é o entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça: "[...] A incidência da agravante do art. 61, II, j, do Código Penal exige demonstração que o agente se valeu do contexto de pandemia para a prática do delito. [...]". (STJ - HC 654255/SP, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 25/05/2021, p. 07/06/2021).

Na terceira etapa, deve ser levada em consideração a causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º da Lei 11.343/06, causa esta que, uma vez verificados seus requisitos, deve ser aplicada, ainda que de ofício.

Observando-se o critério da proporcionalidade e razoabilidade no caso em questão, tem-se que a pena deve ser reduzida em 2/3 (dois terços), nos termos do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, visto que o réu é tecnicamente primário.

Resta, portanto, sua pena definitiva em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo, atualizado.

A este respeito, deve ser acolhido o seguinte preceito doutrinário: "Dispõe o parágrafo, em sua parte final, sobre condições negativas de que o agente não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Toda prova negativa é difícil, de modo que militará em favor do réu a presunção de que é primário e de bons antecedentes e de que não se dedica a atividades criminosas nem integra organização criminosa. O ônus da prova, no caso, é do Ministério Público no sentido de demonstrar a reincidência, os maus antecedentes e a participação em atividades criminosas ou organização criminosa. Não importa que a prova seja difícil para o Ministério Público. Mais difícil seria para o réu que, por sua vez, tem o direito de não ser condenado a não ser que haja prova, ou receber, sem prova, uma pena maior quando a lei permite uma pena mais branda" (GRECCO FILHO, Vicente e RASSI, João Daniel. Lei de Drogas Anotada. São Paulo: Saraiva, 2ª Ed., 2008, p. 106-107).

Com fulcro em tal lição doutrinária e na análise das provas produzidas em juízo, de rigor considerar a causa de diminuição da pena, eis que não restaram comprovados quaisquer dos óbices aduzidos no texto de lei sob comento.

Por conseguinte, excepcionalmente, considerando as particularidades do caso vertente, substituo a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos, em consonância com o art. 44, § 2º, do Código Penal, sendo prestação de serviços à comunidade em local a ser indicado na fase de Execução, e o pagamento de 01 (um) salário mínimo a entidade preferencialmente voltada ao auxílio de dependentes químicos, a ser indicada na fase de Execução.

Em caso de descumprimento da pena alternativa e conversão em pena privativa de liberdade, o regime inicial para cumprimento da pena será o aberto.

Importante ressaltar que o tráfico privilegiado não é definido como crime hediondo, conforme art. 112, § 5º, da Lei de Execução Penal e, portanto, os efeitos decorrentes da hediondez de um delito não são aplicáveis, sendo plenamente possível

o regime inicial em modalidade diferente da fechada.

A pena de multa, eis que não substituída, permanece intacta.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia, para CONDENAR o acusado PAULO SÉRGIO SANTOS DA SILVA como incurso no artigo 33, caput, c.c. o artigo 33, § 4º, ambos da Lei nº 11.343/06, às penas de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo, atualizado, SUBSTITUÍDA a pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direitos, sendo prestação de serviços à comunidade em local a ser indicado na fase de Execução, e o pagamento de 01 (um) salário mínimo a entidade preferencialmente voltada ao auxílio de dependentes químicos, a ser indicada na fase de Execução.

O sentenciado poderá recorrer em liberdade, ante a natureza das sanções aplicadas.

Após o trânsito em julgado, determino, desde logo, a destruição das amostras das drogas apreendidas eventualmente guardadas para a contraprova, nos termos do artigo 72 da Lei nº 11.343/06, devendo a serventia certificar o cumprimento nos autos.

Oficie-se. Adite-se a carta de guia, se necessário, elaborando-se o cálculo da pena de multa aplicada.

Decreto a perda de eventuais valores apreendidos em favor da União, conforme o artigo 63, §1º, da Lei 11.343/06.

O réu fica dispensado do recolhimento das custas processuais, vez que assistido pela Defensoria Pública Estadual e, no cenário dos autos, presume-se a hipossuficiência de recursos.

Após o trânsito em julgado, expeça-se Guia de Execução Definitiva e lance-se o nome do sentenciado no rol dos culpados, arquivando-se, oportunamente.

P.R.I.C.

São Paulo, 16 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA